

1501446-65.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... forma individualizada.

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Ao final da instrução, a prova coligida é robusta, clara e sólida a embasar o decreto condenatório no tocante ao delito de tráfico de drogas.

Segundo foi apurado, guardas civis municipais efetuavam patrulhamento de rotina pelo Bairro Jardim Rosa Garcia II, na Cidade e Comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí

Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Tatuí-SP - cep 18278-440

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501446-65.2021.8.26.0571

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2297252/2021 - DEL.POL.PLANTÃO

TATUI, 21138481 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2582/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI,

2297252 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS GUILHERME CAMARGO RODRIGUES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

1º Juiz(a) de Direito Auxiliar: Dr(a). FERNANDO JOSE ALGUZ DA SILVEIRA

Vistos.

CARLOS GUILHERME CAMARGO RODRIGUES e WILIAN THIAGO SILVEIRA, já qualificados nos autos, foram denunciados e estão sendo processados como incurso na figura típica descrita no artigo 35 da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto, segundo narra a denúncia, no dia 30 de outubro de 2021, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas.

CARLOS GUILHERME CAMARGO RODRIGUES e WILIAN THIAGO SILVEIRA também foram denunciados e estão sendo processados como incursos na figura típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 com incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, pois, consoante relata a denúncia, no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 18h16, na Rua Jorge Salum, nº 149, no Bairro Rosa Garcia II, nesta Cidade e Comarca de Tatuí, traziam consigo, guardavam e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 03 (três) porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 0,5 gramas, 39 (trinta e nove) porções de "crack", subproduto da cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, 04 (quatro) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 3,5 gramas, e 08 (oito) porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 07 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da importância de R\$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) em dinheiro.

Os réus foram notificados (fls. 103 e 104) e ofertaram suas defesas prévias (fls. 115/121 e 128/136).

A denúncia foi recebida em 09 de fevereiro de 2022 (fls. 138/142) e os acusados foram citados (fls. 166 e 169).

Durante audiência foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas e, ao final, os réus foram interrogados. A instrução foi encerrada e as partes ofertaram suas alegações finais orais (fls. 171/179).

Os autos vieram para a conclusão.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada que tramita em desfavor de CARLOS GUILHERME CAMARGO RODRIGUES e WILIAN THIAGO SILVEIRA, os quais, segundo consta da peça inicial acusatória, em concurso material de delitos (artigo 69 do Código Penal), transgrediram os preceitos primários das normas penais incriminadoras inseridas no artigo 33, caput e no artigo 35, ambos da Lei nº 11.343/06, com incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal.

De início, a despeito do quanto argumentado pela Defesa do réu Carlos Guilherme Camargo Rodrigues, não se vislumbra que os agentes públicos envolvidos no flagrante e nos trabalhos periciais tenham agido de modo a comprometer a higidez e a integridade da prova obtida e a vulnerar a cadeia de custódia.

De fato, a chamada cadeia de custódia refere-se ao procedimento que visa preservar a idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado. Neste viés, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode resultar na sua imprestabilidade. Por isso, a higidez da cadeia de custódia insere-se no campo da licitude da prova.

No entanto, dos elementos de informação trazidos aos autos não há dado concreto a indicar que houve quebra na cadeia de custódia capaz de comprometer a credibilidade da prova pericial.

Superada a questão acima apontada, remanesce a matéria de fundo vertente dos autos. Cotejadas as provas colhidas nesta ação penal, conclui-se que os fatos descritos na denúncia não foram cabalmente demonstrados quanto ao delito de associação para o tráfico.

Por isso, de rigor o parcial acolhimento da pretensão punitiva com a condenação dos réus pela prática apenas do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, afastando, ainda, a incidência da agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, conforme será oportunamente explicitado. Deveras, sabe-se que é necessário, para toda e qualquer condenação, que exista juízo exauriente acerca da autoria e materialidade delitiva.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada através do auto de prisão em flagrante delito de fl. 01, boletim de ocorrência de fls. 02/04, auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 07/08, comprovante de depósito judicial de fl. 69, laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls. 70/73 e pela prova oral colhida. De igual modo, a autoria em relação à infração penal apontada é inconteste.

Feitas as considerações iniciais, passa-se à análise da prova colhida em audiência. Durante a instrução, a testemunha JOÃO BATISTA DE ALMEIDA, guarda civil municipal, informou que na data dos fatos duas equipes da Guarda Civil Municipal realizavam patrulhamento nas ruas do Bairro Jardim Rosa Garcia II. Em dado momento, as guarnições foram abordadas por um morador do bairro que relatou ao depoente e seus colegas de profissão que na praça do lago situada na Rua Jorge Sallum havia dois indivíduos realizando a venda de drogas. O delator informou que um dos suspeitos estava com uma camisa verde e o outro com uma camisa amarela. Diante de tais informações, deslocaram-se ao local e depararam-se com dois indivíduos abaixados em um poste. Ao notarem a aproximação da viatura, os suspeitos levantaram-se e dispensaram algo no chão. Foi efetuada a abordagem e o GCM Queiroz foi responsável por realizar a revista dos indivíduos. Com o rapaz de camisa verde, cujo nome era Carlos Guilherme, foi encontrada a quantia de trezentos e cinquenta reais. Já com o acusado Wilian Thiago, que na ocasião trajava uma camisa de cor amarela, foi localizada a quantia de duzentos e setenta e cinco reais. Ainda foi encontrado o objeto dispensado pelo réu Carlos Guilherme e constatado tratar-se de quatro porções de cocaína embaladas a vácuo, conhecidas como Aricanduva. Também foi localizado o objeto dispensado por Wilian, o qual se tratava de três porções de crack. O depoente efetuou buscas no poste em que os réus estavam e lá localizou oito porções de cocaína embaladas a vácuo e trinta e nove porções de crack. Questionados, os réus negaram a propriedade das drogas e não souberam informar a procedência do dinheiro. Os acusados foram presos em flagrante e conduzidos ao Plantão Policial. Ambos são conhecidos nos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Indagado, o depoente salientou que o delator informou que há mais de dez dias os acusados comercializavam drogas no local. Destacou que no local da prisão frequentemente são realizadas abordagens envolvendo a prática do comércio espúrio. Indagado pela Defesa, disse que a abordagem se deu durante o dia e foi possível visualizar com clareza os objetos dispensados pelos acusados, pois a viatura já estava próxima de ambos. Afirmou que já abordou os réus em duas ocasiões anteriores e com eles haviam sido encontradas quantias consideráveis de dinheiro em notas variadas.

O guarda civil municipal JULIO GONÇALVES MACHADO QUEIROZ ratificou na íntegra o depoimento prestado por João Batista. Acrescentou que já avistou e abordou os réus em outras ocorrências no mesmo local. Salientou que havia outras pessoas próximas ao local, mas apenas os réus utilizavam as roupas informadas pelo delator. Por sua vez, perante a Autoridade Policial, o réu CARLOS GUILHERME CAMARGO RODRIGUES manifestou o desejo de permanecer em silêncio (termo de interrogatório de fl. 12). Durante seu interrogatório judicial, ouvido sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa, informou que já foi processado e condenado pela prática do delito de roubo, bem como ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de tráfico de drogas, roubo e furto. Negou a prática dos delitos a ele atribuídos. Disse conhecer o corréu Wilian Thiago apenas porque já jogaram futebol juntos e, no dia, apenas parou para cumprimentá-lo. Não dispensou nenhuma porção de droga. Jogou apenas um cigarro que fumava. As drogas apreendidas não lhe pertenciam. No local havia um senhor pescando. Observou que os guardas civis municipais localizaram as drogas há mais de cinquenta metros do local em que foi abordado. Indagado sobre a procedência do dinheiro com ele apreendido, destacou que há dois ou três meses foi dispensado do trabalho de servente que realizava e o valor era dele proveniente. Destacou que os agentes públicos mentiram para incriminá-lo. Não sabia que o local era conhecido como ponto de venda de drogas. Apontou que estava de passagem no local porque possuía familiares no bairro. Questionado, disse que seguia em direção à sua casa. Não tinha o costume de se encontrar com Wilian Thiago. No dia utilizava um short amarelo e uma camisa verde. Novamente indagado, disse que o dinheiro que com ele estava era referente ao FGTS.

Já o réu WILIAN THIAGO SILVEIRA, em solo policial também se valeu do silêncio (termo de interrogatório de fl. 13). Em Juízo, contou que nunca foi processado e condenado. Na data da prisão residia com sua tia no Bairro Jardim Rosa Garcia, mas alugava uma casa em que pouco permanecia. Não trabalhava à época dos fatos.

Estudava na Escola Professora Altina Maynardes Araújo no período da manhã. Quanto aos fatos, disse que estava com a quantia de dinheiro com ele apreendida. Não dispensou nenhuma porção de droga, pois tanto o interrogando quanto o corréu Carlos Guilherme não as portavam. Ambos não estavam juntos no local. Somente quando a viatura passou é que o interrogando aproximou-se de Carlos Guilherme. Disse que foram abordados por uma equipe da GCM, enquanto outra viatura foi até o local em que as drogas estavam. Disse que foram apreendidas trinta porções de crack e seis porções de cocaína. As porções de crack foram encontradas de um lado da rua, enquanto as porções de cocaína estavam do outro lado da via. Indagado, disse que as porções de crack lhe pertenciam. Não sabe de quem eram as porções de cocaína. Quanto ao dinheiro com ele encontrado, disse que apenas a quantia de cento e vinte e cinco reais era proveniente do tráfico de drogas. Destacou que Carlos Guilherme estava no local esperando uma tia. Sabe que o corréu não reside no Bairro Jardim Rosa Garcia. Na Delegacia de Polícia confessou a venda das drogas no local. Não soube informar se Carlos Guilherme tinha conhecimento de sua confissão prestada no dia da abordagem. Indagado pela Defesa, disse que vendia drogas no local há um mês. Adquiria as porções de outra pessoa. No mesmo dia outros indivíduos também vendiam drogas no local. Afirmou que Carlos Guilherme não estava envolvido com a venda de drogas e foi preso injustamente.

Os depoimentos e os interrogatórios foram captados por meio de sistema audiovisual, nos termos do Provimento CGJ 08/2011 e das Leis nº 11.419/06 e 11.719/08, e através de videoconferência, mediante utilização do aplicativo Teams/Microsoft, com a disponibilização da mídia em pasta digital, em decorrência da pandemia do Covid-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação 62/2020 do CNJ e Comunicado CG nº 284/2020.

Pois bem. Para uma melhor compreensão, procedo à análise dos delitos imputados aos réus de forma individualizada.

DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

Ao final da instrução, a prova coligida é robusta, clara e sólida a embasar o decreto condenatório no tocante ao delito de tráfico de drogas.

Segundo foi apurado, guardas civis municipais efetuavam patrulhamento de rotina pelo Bairro Jardim Rosa Garcia II, na Cidade e Comarca de Tatuí e, em dado momento, um morador do referido bairro os acionou e relatou acerca da prática da mercancia espúria que era realizada na praça do local.

O delator anônimo ofertou detalhes acerca das vestes utilizadas pelos traficantes e, com base em tais informações, os agentes públicos efetuaram diligência a fim de apurar a sua veracidade.

Na ocasião, avistaram os acusados abaixados ao pé de um poste de iluminação existente no local, sendo que Carlos Guilherme trajava uma camisa de cor verde e Wilian Thiago uma camisa de cor amarela, tal qual noticiado pelo informante anônimo.

Ao notarem a presença das viaturas da GCM, os réus levantaram-se e dispensaram algo ao chão. Feita a abordagem, com Carlos Guilherme foi encontrada a quantia de trezentos e cinquenta reais, enquanto com Wilian Thiago foi localizada a quantia de duzentos e setenta e cinco reais.

Os agentes públicos também lograram constatar que os objetos dispensados pelos réus tratavam-se de quatro porções de cocaína embaladas a vácuo, conhecidas como Aricanduva (dispensadas por Carlos Guilherme) e três porções de crack (dispensadas por Wilian Thiago).

Realizadas buscas no poste em que os réus foram flagrados, a equipe encontrou outras oito porções de cocaína embaladas a vácuo e trinta e nove porções de crack, idênticas àquelas antes dispensadas pelos acusados.

Diante da constatação da infração penal, os réus foram conduzidos à Delegacia de Polícia para elaboração do auto de prisão em flagrante e registro da ocorrência. Tais questões estão embasadas pela prova testemunhal e demais elementos carreados aos autos.

Os agentes de segurança foram harmônicos e seguros em seus depoimentos. Nas oportunidades em que ouvidos, apresentaram versões concretas acerca da materialidade e autoria do delito perpetrado pelos réus.

Saliente-se, tanto doutrina quanto jurisprudência são uníssonas em afirmar que os depoimentos prestados por agentes de segurança devem ser críveis até prova em contrário. Os depoimentos prestados pelos guardas civis municipais, como servidores públicos que são, gozam de credibilidade, sendo seus testemunhos plenamente válidos, até porque inexistem impedimentos de ordem moral para afastá-los. A esse respeito, observo que "Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunho ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes." (RT 411/26). Além do mais, seus depoimentos foram submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.

Não bastasse, em seu interrogatório prestado em Juízo, embora intentado afastar seu envolvimento e o liame subjetivo com o acusado Carlos Guilherme, o réu Wilian Thiago confirmou que as porções de crack encontradas no local lhe pertenciam e que ali estava para a venda dos tóxicos.

Ainda, a despeito de ter o acusado tentado isentar seu asseccla da responsabilidade pela venda de drogas no local, tal assertiva não convence.

De fato, as versões trazidas pelos acusados não se sustentam. Sequer Carlos Guilherme conseguiu apresentar argumento crível acerca do motivo pelo qual estava no local. Isso porque, de forma vaga e desprovida de credibilidade, destacou que estava de passagem por ali porque possuía familiares residentes no Bairro, mas não foi até a casa de nenhum deles. Acrescentou que teria parado para cumprimentar Wilian Thiago, pessoa por ele conhecida somente por conta de jogo de futebol.

Ainda, após ser questionado, limitou-se a dizer que seguia em direção à sua casa. Da mesma forma, Carlos Guilherme não logrou justificar com satisfação a origem do dinheiro apreendido em seu poder, pois a indicação de que se tratava de fruto de seu trabalho ou FGTS ficou isolada e desprovida de qualquer elemento apto a corroborá-la.

Já o réu Wilian Thiago, embora tenha confessado de forma parcial a venda de drogas, buscou apontar divergência nos depoimentos dos agentes públicos quanto à localização das porções ilícitas. Ainda, disse que não estava com Carlos Guilherme, mas sabia que ele estava no local aguardando uma tia, informação esta que sequer o corréu apontou. Apontou ter confessado em solo policial a venda de drogas, porém não sabe se Carlos Guilherme tomou conhecimento de sua assunção de culpa. No mais, tentou a todo instante afastar a responsabilidade de seu comparsa.

Não é demais destacar que os guardas civis municipais foram firmes ao destacar que os réus estavam juntos quando avistados pela guarnição, bem como ambos dispensaram as drogas posteriormente localizadas no local, cujas versões merecem prevalecer eis que desprovidas de qualquer mácula.

À vista de tais ponderações, evidente que as versões exculpatórias não se sustentam em face dos firmes depoimentos dos guardas civis municipais responsáveis pela diligência, os quais estão em consonância com os demais elementos constantes nos autos.

Diante de todo o contexto, inegável que a conduta dos acusados se amolda perfeitamente aos verbos-tipo "trazer consigo", "guardar" e "manter em depósito", previstos no preceito primário da norma penal incriminadora prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Nesse sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA - SUFICIÊNCIA - Materialidade e autoria comprovadas - Réu preso em flagrante - Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes - Conduta do apelante que se amolda ao verbo-tipo trazer consigo do artigo 33 da Lei de Drogas - Tipo misto alternativo em que basta que a conduta se subsuma a qualquer dos verbos-tipo para a caracterização da infração - Desnecessidade de dolo específico para a caracterização do tráfico - Negativa do réu isolada diante das demais provas coligidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - PENA - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TRÁFICO PRIVILEGIADO -

CIRCUNSTÂNCIAS ADVERSAS À CONCESSÃO DA BENESSE - "REFORMATIO IN PEJUS" - IMPOSSIBILIDADE - Aplicado pelo MM. Juízo redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, no patamar de um terço - Maus antecedentes do réu comprovados por Certidão - Impossibilidade de aplicação do redutor por expressa vedação legal - Recurso apenas da Defesa, o que impossibilita a "reformatio in pejus" - SENTENÇA - ERRO MATERIAL - CORREÇÃO - Determinação para que, no dispositivo da sentença, conste a condenação do réu por infração do artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343, de 23 de agosto de 2006, à pena de três anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de trezentos e trinta e três dias-multa, no valor mínimo legal - Sentença condenatória mantida, com retificação 'ex officio' - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, COM DETERMINAÇÃO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 9090093-75.2008.8.26.0000, Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Amado de Faria; Origem: Comarca São José dos Campos; Julgamento e Publicação: 06.10.2011 e 13.10.2011) - sem destaques no original.

"Rejeição da Denúncia - Fundamento insubsistente - A conduta descrita na denúncia está tipificada no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Quantidade de droga que autoriza a imputação - Princípio da insignificância que, por outro lado, não tem aplicação em nosso ordenamento jurídico, principalmente em se tratando do grave delito de tráfico de entorpecentes - Tratando-se de crime de ação múltipla, não é necessária a prática de atos de mercancia, bastando, para o seu reconhecimento, que se realize um dos verbos do tipo penal. Recurso provido a fim de receber aquela peça." (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito nº 0008243-89.2014.8.26.0050; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Marcos Corrêa; Origem: Comarca de São Paulo; Julgamento e Publicação: 30.04.2015 e 04.05.2015) - sem destaques no original.

"Tráfico de drogas. Autoria e materialidade do crime fartamente comprovadas. Exame pericial constatando que a substância apreendida é cocaína. Palavra das testemunhas policiais e confissão do apelante de que guardava entorpecentes para terceiro. Configuração do ilícito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 posto que, independente da mercancia efetiva, esta é somente uma das possibilidades em meio aos múltiplos verbos nucleares do tipo, destinados a repreender todas as movimentações do narcotráfico, inclusive as de "ter em depósito" e "trazer consigo" drogas. Absolvição impossível. Penas bem dosadas, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/06. Apelo não provido." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0001799-24.2013.8.26.0099; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Diniz Fernando; Origem: Comarca de Bragança Paulista; Julgamento e Publicação: 10.08.2015 e 15.08.2015) - sem destaques no original.

Convém lembrar não ser preciso para a caracterização da narcotraficância que o agente seja surpreendido no exato momento em que fornece materialmente a droga a terceira pessoa, bastando circunstâncias seguras de que para tanto se destina o tóxico com ele encontrado, como é o caso dos autos.

Ainda, o Código Penal adota a teoria unitária ou monista, na qual, todos os que concorrem para um crime por ele respondem. No caso dos autos, patente a atuação dos réus (pluralidade de indivíduos) e unidade de crime.

Em suma, os réus, previamente ajustados, agiram em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, estando presente o concurso de agentes previsto no artigo 29, caput, do Código Penal.

De mais a mais, as Defesas técnicas não produziram nenhuma prova que pudesse favorecer os acusados e desprestigiar a prova que contra eles recai.

De rigor, portanto, a condenação dos réus à prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (Artigo 35 da Lei nº 11.343/06).

No tocante ao crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, vislumbra-se que as provas amealhadas não se revelam aptas à edição de um édito condenatório, porquanto nada se demonstrou acerca de uma pretensa organização ou animus associativo entre os acusados.

O mero flagrante dos agentes na posse das substâncias entorpecentes, não autoriza a conclusão de que haja uma associação estável e constante para a prática delituosa. Com acerto a observação do eminente professor Vicente Greco filho, in Tóxicos,

prevenção-repressão, 14ª edição, atual. e ampl., São Paulo, Ed. Saraiva, 2011: "Para haver crime autônomo de associação em matéria de entorpecentes é mister um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido de formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris* em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que determina a coautoria. É mister haja o dolo específico: associar para traficar (...) Diante, pois, destas considerações o crime de associação (art. 35) como figura autônoma há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores. Jamais a simples coautoria ocasional, transitória, esporádica, eventual configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração..." - sem destaque no original.

No mesmo sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal, *in verbis*: "Para não confundir-se com o mero concurso de agentes, a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada." (STF, ROHC nº 75.236-5/AM, 1ª Turma, j. 3-6-1997, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJU de 1º- 8-1997, RT 749/584, citado por Renato Marcão, Tóxicos, Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006, Nova Lei de Drogas, Anotada e Interpretada, 7ª edição, Editora Saraiva, p.232) - sem destaque no original.

É que, como cediço, o crime de associação para o tráfico demandaria prova indubitável da existência de uma permanente e estável associação entre os acusados, para o fim da traficância, o que não foi produzido a contento nos autos.

Tal figura típica, diferentemente da simples coautoria ou participação, exige a plena comprovação de que os agentes se achavam previamente associados com a intenção de praticarem o tráfico de drogas, sendo mister, para tanto, a apresentação de elementos probatórios da existência de situações anteriores, delimitadas no tempo e espaço, caracterizadoras da sociedade criminosa e sua permanência e constância.

Saliente-se que os GCM's ouvidos em Juízo, disseram que estavam em patrulhamento de rotina quando foram avisados por um transeunte acerca da venda de drogas no local, ocasião em que promoveram a abordagem dos réus e constataram a prática do comércio espúrio.

A despeito de terem os agentes públicos responsáveis pela diligência indicado que eram diversas as denúncias que recaiam sobre os acusados, por si só, tal informação não basta para justificar o reconhecimento do ânimo dos agentes para a prática da associação ao tráfico, eis que desprovida de qualquer outro elemento capaz de reforçá-la.

Por isso, os elementos de informação não são hábeis a aferir com a necessária certeza a caracterização da estabilidade para a prática delitiva, motivo pelo qual as provas acusatórias não são suficientes para o acolhimento da imputação quanto ao delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual, a absolvição dos acusados com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, neste sentido, é medida que se impõe.

DOSIMETRIA DA PENA.

Adotando-se o critério trifásico, nos termos do art. 68 do Código Penal, observando, ainda, a Lei n. 11.343/06, atual Lei de Drogas, passo à fixação da pena.

RÉU CARLOS GUILHERME CAMARGO RODRIGUES.

Na primeira fase do critério trifásico, atento ao artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu ostenta condenação anterior que por caracterizar reincidência, nos termos da Súmula nº 241 do STJ, será ponderada na etapa seguinte.

Ainda, a anotação inserta na certidão de fls. 31/33 referente ao Processo nº 1500148-10.2020.8.26.0624 deve ser desconsiderada nesta etapa, atentando-se ao

verbete sumular nº 444, do STJ, segundo o qual “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Por outro lado, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta do agente extrapolou o esperado pelo tipo penal em apreço, face à natureza, diversidade e quantidade de entorpecentes apreendidos em seu poder, frise-se, 03 (três) porções de “crack”, subproduto da cocaína, com peso bruto de 0,7 gramas e líquido de 0,59 gramas; 04 (quatro) porções de cocaína, com peso bruto de 3,83 gramas e líquido de 3,2 gramas; 39 (trinta e nove) porções de “crack”, subproduto da cocaína, com peso bruto de 8,03 gramas e líquido de 6,45 gramas; e 08 (oito) porções de cocaína, com peso bruto de 7,78 gramas e líquido de 6,54 gramas (laudo de fls. 70/73).

Neste aspecto, inclusive, confira-se: “TJ-SP - Apelação Criminal nº 0028720-96.2014.8.26.0224; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Márcio Eid Sammarco; Origem: Comarca de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Julgamento: 06.06.2019; Publicação: 07.06.2019”.

Além disso, destaco que a cocaína e o crack possuem efeitos deletérios àqueles que deles fazem uso com alta probabilidade de dependência imediata e catastrófica após a sua ingestão, bem como se apresentam extremamente nocivos à sociedade como um todo, tornando-se um problema endêmico de saúde pública em todo o território nacional.

Assim, pautando-se pela proporcionalidade e razoabilidade exigida, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto) fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de multa de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, como já destacado, o réu possui condenação anterior, consoante certidão de fls. 31/33 - Processo nº 1502748-70.2018.8.26.0269 -, de modo que incide ao caso a circunstância agravante da reincidência prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal.

Por outro lado, assim como já declinado nos autos do Processo nº 1501160-87.2021.8.26.0571, ressalvado o entendimento até então adotado por este Juízo em relação à circunstância agravante disposta no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (crime praticado em período de calamidade pública), passo a adequar-me à orientação recorrente provinda das Cortes Superiores no tocante à natureza subjetiva da referida agravante, razão pela qual entendo a sua não incidência no caso em comento.

Neste sentido, confira-se:

“Em relação à agravante prevista no art. 61, I, “j”, do Código Penal, verifica-se que a sanção do paciente foi novamente exasperada em 1/6, porque os fatos foram cometidos durante a pandemia do coronavírus, estado esse de calamidade pública; Todavia, entendo que deve ser afastada a referida agravante, pois sua incidência pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa.” (STJ - AgRg no HC 677.124/SP; 5ª Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julgamento: 03.08.2021).

“Evidenciado, no caso, que o reconhecimento da agravante decorrente do estado de calamidade pública, ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, não possui nenhum nexo com o crime praticado, inviável sua incidência, sob pena de violação à culpabilidade, em seu sentido principiológico.” (STJ - AgRg no HC 669.508/SP; 6ª Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julgamento: 15.06.2021).

De igual modo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Veja-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena redimensionada - Afastamento da agravante da calamidade pública - Ausência de nexo causal - Regime prisional fechado mantido - Recurso parcialmente provido.” (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501003-51.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal;

Relator(a): Desembargador(a) Jucimara Esther de Lima Bueno; Origem: Foro de Tatuí - 2ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 15.02.2022).

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - APREENSÃO DE 47,1 GRAMAS DE COCAÍNA E 21,5

GRAMAS DE MACONHA - MERCANCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO CORRETA, POIS LASTREADA EM PROVA FIRME DA AUTORIA E MATERIALIDADE. PENAS - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE. Não há prova de que o réu se valeu da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501141-18.2020.8.26.0571; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Willian Campos; Origem: Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Julgamento e Publicação: 01.09.2021).

Ausentes circunstâncias atenuantes, a pena intermediária deve ser recrudescida em 1/6 (um sexto), chegando ao quantum de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena.

O réu não faz jus à redução prevista na causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, porquanto não preenche os requisitos legais, porque é reincidente em crime doloso.

Reforçando ainda mais o afastamento da benesse, infere-se do seu interrogatório e da certidão de fls. 29/30, que o réu ostenta passagens pela Vara da Infância e Juventude, notadamente pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, roubo e furto.

De fato, é certo que registro de ato infracional não se presta a gerar maus antecedentes ou reincidência. Não obstante, é apto e suficiente para afastar a incidência do tráfico privilegiado, pois denota que sua conduta tem sido permeada pela prática de atos antissociais.

Neste viés, inclusive, "... conquanto o ato infracional (...) não possa ser considerado para fins de reincidência, ou mesmo como maus antecedentes, serve perfeitamente para demonstrar sua periculosidade, bem assim sua propensão ao cometimento de delitos da mesma natureza (...)" (HC 33614/DF; 5ª Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; j. 2-6.2005; DJ 20-6-2005; p. 302).

Ainda:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E NÃO EXCEDENTE A OITO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DO ENTORPECENTE. MODO INTERMEDIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. MANIFESTA ILEGALIDADE PARCIALMENTE VERIFICADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4º, da Lei n.11.343/2006). 3. Concluído pela instância antecedente, diante de anterior registro de ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, que o paciente se dedica a atividade criminosa, a alteração desse entendimento - para fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes. (...)" (HC 435.685/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018) - destaquei. Destarte, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. RÉU WILIAN THIAGO SILVEIRA.

Na primeira fase, observo que as circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao acusado.

Diferentemente do réu Carlos Guilherme, deixo de considerar a quantidade e a natureza da droga apreendida nesta fase, a fim de ponderá-las na terceira etapa da dosimetria da pena, notadamente para o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Justifico tal posicionamento de modo a evitar a incidência do bis in idem, em atenção ao entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de que “as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (STF, Tema 712, publicado em 06.05.2014).

No mesmo sentido:

“Cumpro destacar que, em sessão realizada no dia 19.12.2013, o Pleno do STF, ao julgar os HCs 112.776 e 109.193, ambos da relatoria do Min. Teori Zavascki, firmou orientação no sentido de que, em caso de condenação por tráfico ilícito de entorpecentes, a natureza e a quantidade da droga apreendida apenas podem ser levadas em consideração em uma das fases da dosimetria da pena, sendo vedada sua apreciação cumulativa. Na ocasião, ficou consignado que cabe ao juiz escolher em qual momento da dosimetria essa circunstância vai ser levada em conta, seja na primeira, seja na terceira, observando sempre a vedação ao bis in idem. No presente caso, o Juiz de 1º grau, ao realizar a fixação da pena, levou em consideração a quantidade e a natureza da droga tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria para elevar a pena do recorrente, o que é vedado nos termos da jurisprudência desta Corte. Assim, manifesto-me pela existência de repercussão geral da questão constitucional debatida e pela reafirmação da jurisprudência desta Corte, de modo a fixar o entendimento no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena” (STF - ARE 666.334/AM; Rel. Min. Gilmar Mendes; j. 03.04.2014).

Por isso, fixo a pena-base em seu patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa, como já declinado anteriormente, não há se falar no reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (crime praticado em período de calamidade pública decretada pelo Governo Federal em decorrência da pandemia do coronavírus - Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020), eis que para sua incidência, dada a sua natureza subjetiva, deve haver provas concretas de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitativa, o que não se vislumbra na hipótese.

O réu faz jus à circunstância atenuante disposta no artigo 65, inciso I, do Código Penal, eis que na data do fato era menor de vinte e um anos. No entanto, deixo de considerá-la, pois a pena nesta etapa não pode ficar aquém do mínimo legal, em atenção ao teor da Súmula nº 231 do STJ.

Não há se falar na confissão do agente. Com efeito, “a chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas discriminantes ou exculpantes, não tem o condão de ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal” (HC 231363/SP, Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, Data do Julgamento: 18/06/2014, DJe 15/09/2014). Ao buscar, com sua versão, excluir o seu envolvimento com o corréu, o acusado não confessou o crime. Buscou, na realidade, atenuar a gravidade de sua conduta, em nada contribuindo para a solução da lide.

Desta feita, a pena intermediária fica inalterada.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento de pena.

Da mesma forma, não há se falar em causas de diminuição de pena, notadamente a benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Apesar de primário, pelas circunstâncias em que se deu o flagrante ficou comprovado que os réus estavam dedicados à traficância. Embora não se tenham provas exatas, inconcussas, sobre a associação para o tráfico, situação não evidenciada no presente feito, ou ainda, a participação do réu em organização criminosa, evidente que, in casu, a quantidade de droga apreendida, sua diversidade e natureza, aliada ao concurso eventual de agentes, são fatores que não autorizam a incidência da benesse legal, pois demonstram que o acusado se dedica às atividades criminosas.

Acerca do tema, inclusive:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. REGIME INICIAL FECHADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. IMPOSIÇÃO JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal a quo negou o benefício, concluindo que o ora agravante se dedicava à atividade criminosa do tráfico, diante da quantidade e da natureza droga apreendida e das circunstâncias do fato, de maneira que entender diversamente, como pretendido, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Inafastável a aplicação do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Esta Corte tem decidido que a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias em que cometido o tráfico, podem evidenciar a dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação da minorante. In casu, a utilização da quantidade/natureza da droga apreendida para elevar a pena-base (primeira fase) e para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas (terceira fase), por demonstrar que o acusado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, não configura bis in idem. Diversa é a hipótese tratada no ARE n. 666.334 (Repercussão Geral), no qual o Pretório Excelso passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade/natureza da droga "tanto na primeira fase de fixação da pena, como circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006" (ARE 666.334/RG, Rel.: Ministro GILMAR MENDES, DJ de 6/5/2014). 3. A quantidade e natureza da droga apreendida - 500 invólucros de cocaína e 9 porções de maconha - constituem fundamentos idôneos para o agravamento do aspecto qualitativo da pena, ou seja, para a fixação de regime mais gravoso (fechado). 4. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no AREsp: 1630521 SP 2019/0362668-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgamento: 26/05/2020, Data de Publicação: DJe 09/06/2020).

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PACIENTE CONDENADO À PENA CORPORAL DE 5 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME PRISIONAL FECHADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÃO PROVISÓRIA ANTERIOR. OFENSA À SUMULA N. 444 DESTA CORTE. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICA-SE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MONTANTE DA PENA QUE NÃO PERMITE O BENEFÍCIO. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE QUE ENSEJAM O REGIME INICIAL SEMIABERTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) - Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. - Hipótese em que inexistente ilegalidade quando da não aplicação do privilégio, pois a Corte local apontou a dedicação do paciente às atividades ilícitas, destacando a quantidade e a variedade dos entorpecentes apreendidos e as circunstâncias em que o delito ocorreu, notadamente agravadas pelo fato de o acusado contar com condenação provisória pela prática do mesmo delito e por terem sido apreendidos 536 tubos plásticos vazios. Modificar tal conclusão requer o revolvimento fático probatório, inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes." (STJ, HC 374992 / SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 07/02/2017) - destaquei.

Acrescente-se que o benefício previsto no § 4º, do artigo 33, não pode ser aplicado indistintamente, devendo ser aplicado aos casos específicos, ou seja, desde que preenchidos os seus requisitos, cuja interpretação é realizada de forma restritiva,

a fim de se prestigiar aquele que real e efetivamente mereça ser beneficiado com a redução da pena, o que não é o caso do acusado.

Não havendo outras causas modificadoras, a reprimenda fica estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de multa de 500 (quinhentos) dias-multa. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E BENESSES LEGAIS.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por restarem não atendidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal; o regime de cumprimento fixado para o tráfico de entorpecentes e a própria natureza do delito, que é móvel de grande parte de outros crimes cometidos para a manutenção do vício, impedem a concessão da benesse por restar desatendido o inciso III do dispositivo legal retro mencionado.

Além do mais, não se olvida que o réu Carlos Guilherme é reincidente, de modo que a concessão da benesse encontra óbice no inciso II, do artigo 44; bem como o montante de pena imposta aos acusados supera o limite disposto no inciso I, do citado artigo.

Pelas mesmas razões, desatendidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal, inviabilizando a suspensão condicional da pena.

Fixo, como regime inicial de cumprimento de pena, observadas as colocações feitas por ocasião da não substituição da pena privativa, o REGIME FECHADO, único que se mostra compatível com a gravidade do delito e sua potencialidade lesiva.

Ainda quanto a fixação do regime inicial fechado, colhem-se os seguintes julgados proferidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“TRÁFICO DE DROGAS PEDIDO SUBSIDIÁRIO - FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO INADMISSIBILIDADE - REGIME INICIAL FECHADO ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE DELITO EQUIPARADO A HEDIONDO - INTELIGÊNCIA DA LEI Nº 11.464/2007. “Ressalto que há determinação expressa no artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, de que as penas por crime hediondo ou equiparado iniciam-se no regime fechado”. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0057527-71.2011.8.26.0050; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Marco Antonio Marques da Silva; Origem: Comarca de São Paulo; Julgamento e Publicação: 27.06.2013 e 05.07.2013) - sem destaques no original.

“No concernente ao regime prisional impositivo à espécie, também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei nº 11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da instituição familiar” (TJ-SP - Apelação Criminal nº 990.09.042255-6; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Paulo Rossi; Origem: Comarca de Mogi das Cruzes; Julgamento e Publicação: 01.07.2009) - sem destaques no original.

“Tráfico de drogas Recurso defensivo pleiteando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06 e a fixação do regime prisional aberto - Provas francamente incriminadoras - Condição de usuário que não elide a concomitante atividade de traficância - Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Pena que não comporta reparo. Réu beneficiado com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Regime prisional fixado com critério - Crime equiparado a hediondo, ensejando a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito - Personalidade deturpada, causadora de risco à ordem pública, de quem envereda para a prática desse tipo de criminalidade - Inaplicabilidade do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal - A competência para se discutir a respeito da detração penal é do juízo das execuções - Negado provimento.” (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0001719-19.2014.8.26.0263; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Relator(a): Desembargador(a) Fernando Simão; Origem: Comarca de Itai; Julgamento e Publicação: 10.09.2015 e 14.09.2015) - sem destaques no original.

“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em local conhecido como ponto de venda de

drogas, ao pressentir a iminência da abordagem por guardas municipais, desvencilha-se de sacola contendo 6 porções de maconha, 19 porções de cocaína e 82 pedras de crack. Localização, em seu poder e ao ensejo de revista, de R\$ 62,00 sem comprovação satisfatória de origem. Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões exculpatórias dissonantes e das mais inconsistentes. Alegação de flagrante forjado repelida. Destinação mercantil das drogas bem evidenciada. Pleito de desclassificação da conduta repelido. Condenação, pelo tráfico, bem decretada. Penas que já beneficiam o acusado. Redução, com lastro no artigo 33, § 4º, não questionada pela acusação. Substituição